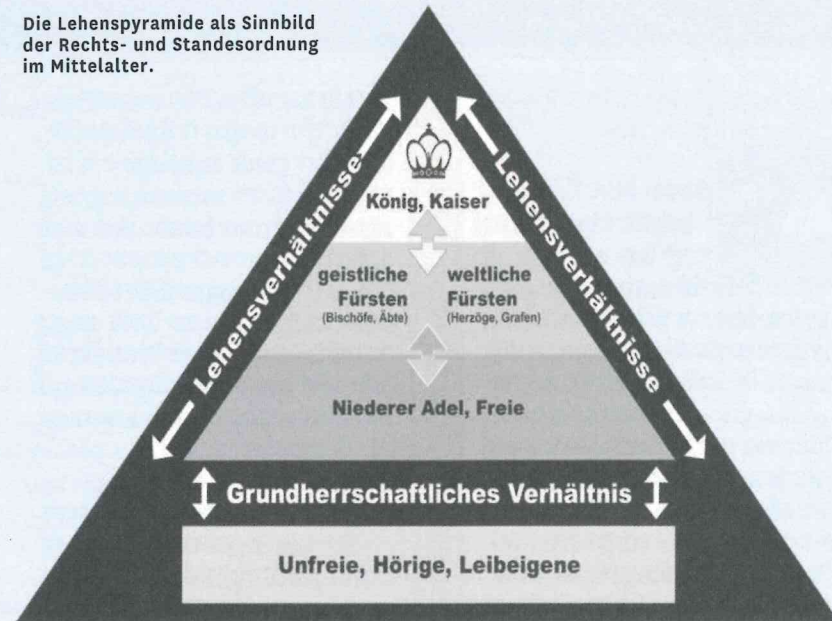


Die Lehenpyramide als Sinnbild der Rechts- und Standesordnung im Mittelalter.



Das aus diesen beiden Elementen gebildete Lehen war höchst persönlich und endete im Prinzip mit dem Tod einer der beiden Seiten. Beim Tod des Königs (*Herrenfall*) hatten die Vasallen seinen Nachfolger innerhalb Jahresfrist um Leheneserneuerung zu bitten. Verstarb der Vasall (*Mannesfall*), hatten seine Erben beim König um Erneuerung nachzusuchen. Erben waren die Söhne oder Enkel des Vasallen. Fehlten männliche Nachkommen, konnten auch weibliche in das Lehenverhältnis treten. Mit der Zeit wurden das Lehen und die mit dem Lehenverhältnis verbundenen Ämter erblich und innerhalb der Familie weitergegeben. Nur bei Treuebruch (Felonie) konnte der König das Lehen noch einziehen.

22 Lehenpyramide Mit dem Lehenwesen wurde der oberste Adel an das Königtum gebunden. Der Adel verlieh seinerseits die Lehen oft weiter an Untervasallen. Es bildete sich eine Lehenpyramide, an deren Spitze der König stand und dessen politische Herrschaft so bis nach unten gesichert wurde. Für das Gebiet der heutigen Schweiz finden sich seit dem 12. Jh. in breiterem Umfang historische Belege. Die herrschenden lokalen Geschlechter, wie die Savoyer und Habsburger, liesen in Lehenbüchern die Pflichten und Rechte ihrer Untervasallen festhalten. Mit dem Zerfall der Königsmacht rückten die personenrechtlichen Bindungen, die dieser Form von Herrschaft zugrunde lagen, in den Hintergrund. Die Herzogtümer wurden nun zu rein territorial definierten Lehenfürstentümern. Das schuf die Voraussetzung für den Aufbau territorialer Landesherrschaften seit dem Spätmittelalter (siehe dazu Rz. 124 ff.)

2.5 Grundherrschaft

Mit dem Lehenwesen verknüpft war die Grundherrschaft. Dies war eine Rechtsfigur, welche die Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Bodens regelte. Die Vasallen erhielten – wie dargestellt – für ihre Dienste von ihrem Lehenherrscher Grund und Boden zur Verfügung, bewirtschafteten diesen aber in der Regel nicht selbst, sondern verliehen ihn an unfreie Bauern. Die Grundherrschaft bildete damit die unterste Ebene der Lehenpyramide. Anders als die heutige Pacht war sie aber nicht ein rein privatrechtliches Rechtsverhältnis. Die Grundherren hatten vielmehr auch hoheitliche Rechte über die Menschen, die ihr Lehen bewirtschafteten. Sie durften von ihnen nicht nur Abgaben verlangen, sondern übten auch die Polizeigewalt und die Gerichtsbarkeit über sie aus. Die Grundherrschaft umfasste also sowohl die Herrschaft über den Grund und Boden, als auch die Herrschaft über die Menschen, die diesen Boden zur Bearbeitung und wirtschaftlichen Nutzung verliehen bekamen. Der Grundherr hatte, modern gesagt, sowohl privatrechtliche wie öffentlichrechtliche Befugnisse.

Die Bauern, die ein Lehen bewirtschafteten, nannte man *Eigenleute* oder *Hörige*. Sie waren nicht rechtlose Sklaven, denn die Grundherrschaft umfasste gegenseitige Rechte und Pflichten. Diese gestalteten sich vereinfachend dargestellt wie folgt:

23 Pflichten und Rechte

- Die Bodenerträge gehörten dem Bauern. Er hatte aber die Pflicht zur Ablieferung eines jährlichen *Grundzinses*. Dieser stellte für den Grundherrn ein regelmässiges Einkommen und damit eine materielle Existenzgrundlage dar.
- Starb ein grundhöriger Bauer, ging sein Nutzungsrecht an Grund und Boden, an Haus und Hof auf seine Erben über. Der Grundherr hatte indessen Anspruch auf den (*Tod-*)fall: Die Erben mussten ihm die kostbarsten Stücke der Fahrhabe, z. B. das beste Stück Vieh (das *Besthaupt*) oder das beste Kleid hergeben, womit er sich einen weiteren Teil des Arbeitsertrages seines Hörigen sicherte. Verstarb der Hörige kinderlos, ging oft dessen gesamte Fahrhabe an den Grundherrn.
- Die Grundhörigen bildeten eine Genossenschaft, die dem vom Grundherrn gegebenen Hofrecht unterstand. Über Streitigkeiten innerhalb dieser Genossenschaft entschied das vom Grundherrn eingesetzte *Hofgericht*. Dieses tagte mehrmals jährlich, an festgesetzten Terminen im Kirchenkalender, unter Vorsitz des Grundherrn oder seines Stellvertreters (Vogt, Meier, Ammann) und mit Beisitz von angesehenen Männern aus der Grundherrschaft.
- Hörige waren bei der Wahl ihrer Ehegatten oft nicht frei, sondern auf die Mitglieder der Genossenschaft beschränkt. Es bestand also ein *Verbot der ungenossamen Ehe*. Auf diese Weise sicherte sich der Grundherr sein Erbrecht am Vermögen des Hörigen im Erbfall. War gegen dieses Verbot verstossen worden, konnte der Grundherr den ganzen Nachlass des verstorbenen Hörigen konfiszieren.

- Das Nutzungsrecht der Hörigen am grundherrlichen Boden war meistens vererbbar, oft über eine bestimmte Anzahl von Generationen hinweg. Das Eigentum des Grundherrn war auf diese Weise stark eingeschränkt. Solange die Hörigen ihren Pflichten nachkamen, hatte der Grundherr kaum die Möglichkeit, das Gut wieder an sich zu ziehen.
- Der Grundherr schuldete seinen Hörigen Schutz und Schirm. Er hatte sie vor räuberischen und kriegerischen Angriffen zu schützen, vor übergeordneten Gerichten zu vertreten und ihnen in Notzeiten die Grundzinsen zu erlassen.

24 Geistliche und weltliche Grundherren Für das Gebiet der heutigen Schweiz finden sich ab dem 8. Jh. Hinweise auf kleinere und grössere Grundbesitzkomplexe. Wichtige Grundeigentümer waren neben dem Adel oft Abteien und Klöster wie z. B. St. Gallen, Muri, das Fraumünster, Einsiedeln oder Engelberg. Das Kloster St. Gallen etwa erwarb bis zum Hochmittelalter umfassende grundherrschaftliche Besitzungen. Für das Benediktinerkloster Muri listeten die um 1160 entstandenen *Acta Murensia* das Grundeigentum vom Elsass bis in die Innerschweiz auf. Die Klöster hatten, anders als manche adlige Grundherren, den Ruf, milde und grosszügig zu sein. Für die Grundhörigen galt: „Unter dem Krummstab (des Abtes) lebt sich's gut!“

Oft fand sich eine Vielzahl unterschiedlichster Grundherren nebeneinander. So war etwa über das Gebiet des heutigen Kantons Zug im Hochmittelalter eine Menge von grösseren und kleineren grundherrlichen Höfen verstreut. Geistliche Grundherren, oft auch nur über einzelne Höfe, waren hier das Fraumünster in Zürich, das Kloster Einsiedeln, das Kloster Muri, das Kloster St. Blasien im Schwarzwald, das Kloster Engelberg, das Stift Beromünster, das Kloster Kappel, das Kloster Frauental und die Johanniterkomturei Bubikon. Unter den weltlichen Grundherren fanden sich die Kyburger und Lenzburger, später die Habsburger, die Freiherren von Rüssegg, die Edlen von Hünenberg, die Freiherren von Wolhusen, die Edlen von Cham, die Ritter von Ebnet und die Edlen von Hertenstein.

25 Freie Bauern Neben den Grundherrschaften existierten stets auch freie Bauern. Vor allem in den alpinen Zonen der Zentralschweiz konnte sich die Grundherrschaft generell wenig durchsetzen. Die Zahl der grundhörigen Menschen war im Gebiet der heutigen Schweiz niedriger als in anderen Gegenden Europas. Zudem kam es im 14. Jh. zu einer Ablösungsbewegung, in welcher sich ganze Talschaften des Alpen- und Voralpenraumes aus der Grundherrschaft loskauften. Das erzeugte im Ausland für die Folgezeit das Bild der „freien Schweizer“, welches aber nicht wirklich zutraf, denn noch im 19. Jh. war mancherorts die Ablösung der aus der Grundherrschaft hervorgegangenen Grundlasten ein politisches Traktandum (vgl. unten Rz. 317).

2.6 Stammesrechte

Aus der zweiten Hälfte des 5. Jhs. sind neben der Gesetzgebung der fränkischen Könige verschiedene Stammesrechte überliefert geblieben. Die Verschriftlichung von zuvor nur gelebtem und mündlich tradiertem Recht ist Ausdruck der lateinischen Schriftkultur, mit der die ursprünglich schriftlosen germanischen Stämme in fränkischer Zeit in Berührung kamen. Die Stammesrechte sind Aufzeichnungen der in einem Stammesgebiet bestehenden Rechtsgewohnheiten. Man nennt sie auch Volksrechte oder *leges barbarorum*. Allerdings enthalten sie kaum je ausschliesslich germanisches Recht. Denn bei der Niederschrift hielten sich die Verfasser, die *prudentes*, meist rechtskundige Kleriker und vornehme Laien, nicht strikt an das überlieferte Gewohnheitsrecht. Vielmehr vermischten sie dieses oft mit königlichem Satzungsrecht, dem Recht der Kirche und mit römischem Recht. Auf diese Weise lebte neben germanischen Rechtsvorstellungen auch spätrömisches Recht fort. Auch wandelten die Autoren die Normen nach den jeweiligen Zeitbedürfnissen ab. Die Stammesrechte zeichnen so ein facettenreiches Bild der Rechtsvorstellungen des Frühmittelalters. So vermischten sich nicht nur die verschiedenen Kulturen, sondern auch die verschiedenen Rechtstraditionen.

Die Stammesrechte galten zunächst nicht in einem bestimmten Gebiet, sondern für einen bestimmten Personenkreis. Es galt, nach heutiger Lesart, das Personalitätsprinzip. Die burgundischen und fränkischen Herrscher liessen nicht nur das Recht der verschiedenen germanischen Stämme, sondern auch das Recht der Nachfahren der romanischen Bevölkerung in ihrem Herrschaftsgebiet aufzeichnen. In diesen *leges* ist der Anteil an spätrömischem Recht besonders gross. Erst mit der zunehmenden Vermischung der Bevölkerung wurden für alle Menschen in einem Gebiet die gleichen Normen erlassen. Das war der Übergang zum Territorialitätsprinzip: Aus dem Volksrecht wurde Territorialrecht.

Die Feststellung des Rechts diente der Stärkung der Herrschaft der Stammesführer, aber auch der Festigung des Friedens im Stammesgebiet. Ob die einzelnen Bestimmungen dieser Stammesrechte wirklich zur Anwendung gelangt sind, ist eine andere Frage. Manchmal ging es um bloss gewünschtes Recht. Das aufgezeichnete Stammesrecht war auch keineswegs erschöpfend; oft enthielt es nur einen Teil des gesamten Rechtsstoffes eines Stammes. Die aus heutiger Sicht unsystematischen Rechtstexte enthalten unter anderem Normen staats-, privat- und prozessrechtlicher Natur sowie erste Ansätze strafrechtlicher Regelungen.

Die Forschung kennt eine ganze Reihe solcher Stammesrechte. Ihre Entstehung, Inhalte und Nachwirkungen wurden von einer älteren Generation von Rechtshistorikern durch minutiösen Vergleich der erhalten gebliebenen Handschriften und mit unermüdlichem Gelehrtenfleiss erforscht. Als wichtige Rechtsquelle im Übergang von der Spätantike zum Mittelalter ist zunächst die

26 Verschriftlichung der Rechtsgewohnheiten

27 Personalitätsprinzip

28 Geltendes oder gewünschtes Recht?

29 Lex Romana Visigothorum

Gda
26
2. Ed.
2. Ex.

René Pahud de Mortanges

Dr. iur., Professor an der Universität Freiburg i.Ue.

Schweizerische Rechtsgeschichte

Ein Grundriss

2., ergänzte und verbesserte Auflage



Umschlagbild

Die Justitia auf dem Gerechtigkeitsbrunnen in der Altstadt Bern symbolisiert die Gerechtigkeit. In ihren Händen hält sie ihre traditionellen Attribute: das Schwert und die Waage. Ihre Augen sind verbunden, denn die Justiz soll ohne Ansehen von Rang und Stand urteilen. Zu ihren Füßen sitzen die vier irdischen Mächte: der Papst, der Kaiser und (nicht sichtbar) der Sultan und der Schultheiss von Bern. Sie stehen für die vier Arten von Regierung nach frühneuzeitlichem Verständnis: die Theokratie, die Monarchie, die Autokratie und die Republik. Alle sind zu Gerechtigkeit verpflichtet.

Die Statue und der Brunnen wurden 1543 vom Bildhauer Hans Gieng (1525–1562) geschaffen und im Laufe der Zeit öfter renoviert. 1798 entfernten die einmarschierenden Franzosen Schwert und Waage der Justitia, um damit den Untergang des Alten Bern zu dokumentieren. 1986 rissen einige Mitglieder der Projurassischen Separatismusbewegung Béliers die Figur von ihrem Sockel und zerstörten sie damit, was schliesslich noch das Bundesgericht beschäftigte (vgl. BGE 117 IV 437). Nach ihrer Restauration wurde die Statue im Berner Historischen Museum aufgestellt; auf dem Brunnen steht seit 1988 eine Kopie.

Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts wurden nach dem Vorbild der Berner Justitia in verschiedenen anderen Schweizer Städten ähnliche Gerechtigkeitsbrunnen geschaffen.

Originalfoto: Autor

Fotobearbeitung und Umschlaggestaltung: Eveline Spicher-Bürgy

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist weltweit urheberrechtlich geschützt. Insbesondere das Recht, das Werk mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und downloading) teilweise oder ganz zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich beim Verlag. Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlags.

© 2017 Dike Verlag AG, Zürich/St. Gallen

ISBN 978-3-03751-838-0

www.dike.ch

Vorwort zur 2. Auflage

Da dieser Grundriss der schweizerischen Rechtsgeschichte bei den Studierenden und Kollegen eine vorwiegend positive Aufnahme gefunden hat, erlaube ich mir, eine konzeptionell unveränderte zweite Auflage vorzulegen. Ich bin mir bewusst, dass man die Geschichte des Rechtes in der Schweiz auch anders präsentieren könnte, etwa fokussiert auf politische und rechtliche Themen oder indem man verstärkt die transnationalen Verflechtungen in den Vordergrund rückt. Das hiesse freilich, ein ganz neues Buch zu schreiben. Die zweite Auflage beschränkt sich indessen darauf, Fehler zu bereinigen, Textpassagen anhand neuer Forschungsergebnisse zu aktualisieren sowie die Bibliographie und die Rechtsentwicklung der letzten zehn Jahre nachzuführen. Die Schweiz verfügt über eine überaus produktive und kreative Geschichtswissenschaft, deren Erkenntnisse auch für rechtshistorische Fragestellungen von Gewinn sind.

Am augenfälligsten ist die optische Veränderung des Buches. War die Bebilderung der ersten Auflage vergleichsweise rudimentär, wird nun mit einer Vielzahl – auch in Farbe – reproduzierter Bilder versucht, Rechtsdokumenten und Rechtsanwendung Gestalt und im Text erwähnten Juristen und Politikern ein Gesicht zu geben. Diese ganz neue Dimension des Buches ist der Verdienst meiner langjährigen Mitarbeiterin Frau Eveline Spicher-Bürgy, die über viele Monate hinweg mit grosser Kreativität und Hartnäckigkeit passende Bilder aufgestöbert und ausgesucht, aufbereitet und in den Text eingefügt hat. Sie hat auch für jedes Bild die Bildrechte eingeholt, was ein nicht immer einfacher Prozess war. Für diese ganze, enorme Arbeit möchte ich ihr sehr herzlich danken! Unser gemeinsames Bedauern ist, dass es nicht möglich war, mehr Bilder von Frauen zum Abdruck zu bringen. Das ist ein sinnenfälliger Ausdruck der Tatsache, dass bis ins 20. Jahrhundert Rechtswissenschaft und Rechtsanwendung ausschliesslich von Männern betrieben wurde (siehe dazu Kap. 11.1).

Danken möchte ich sodann Herrn Dr. Bruno Schmid und Herrn Dr. Urs Fasel für ihre Hinweise auf Corrigenda und ihre inhaltlichen Anregungen sowie meinen Mitarbeitern Frau Daniela Nyffenegger, MLaw, und Herr Christian Reber, Master of Arts in Religionsstudien, für die gewissenhafte Überarbeitung der Register. Sehr zu Dank verpflichtet bin ich auch den Archiven und anderen Stellen für das Zurverfügungstellen der Bilder und die Einräumung der Bildrechte, letzteres manchmal unter Verzicht auf eine finanzielle Abgeltung. Schliesslich danke ich Herrn Jérôme Voumard, Verlags- und Programmleiter, und Herrn Bénon Eugster, Herstellungsleiter des DIKE-Verlages, für die wiederum sehr angenehme Zusammenarbeit auf dem Weg vom File zum Buch.